

SOCIEDADES ANÓNIMAS

CONSTITUCIÓN

§ 179. LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS. CARACTERÍSTICAS

Destacamos la enorme importancia que las sociedades anónimas tienen como instrumento de concentración de capitales para la realización de empresas de gran envergadura, a punto tal que han sido calificadas como pilares fundamentales del capitalismo moderno.

Sus rasgos tipificantes son los siguientes:

1. Se admite su constitución por una sola persona o más.

2. Su capital social se representa por acciones y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas.

3. Las acciones se representan en títulos libremente negociables.

4. Sus órganos se encuentran totalmente diferenciados y reglamentados específicamente por la ley 19.550. Su gobierno corresponde a la **asamblea de accionistas**, su administración al **directorio** y su representación al **presidente del directorio** y, finalmente, la fiscalización es en principio otorgada a un órgano permanente y específico denominado **sindicatura o consejo de vigilancia**.

La ley 19.550, consciente de la enorme importancia que revisten las sociedades anónimas para el desarrollo de la economía capitalista, ha sido muy minuciosa en la reglamentación de su constitución y funcionamiento, dedicando a ellas casi ciento cincuenta artículos (163 a 312), en el convencimiento de que albergan a un gran número de inversores y que resultaba necesario reglamentar minuciosamente el funcionamiento de estas compañías y el ejercicio de los derechos de quienes la integran, así como su necesario control externo por un organismo especializado.

§ 180. CONSTITUCIÓN DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS. LA CONSTITUCIÓN POR ACTO ÚNICO

Si bien la ley autoriza la constitución de las sociedades anónimas por instrumento público y por acto único o por suscripción pública (art. 165, ley 19.550), la experiencia recogida desde el año 1972 demuestra que solo se fundan sociedades por acciones deben ser constituidas necesariamente por instrumento público, que es comúnmente la **escritura pública**, aunque la reforma de sus estatutos no requiere idéntica formalidad, porque es diversa la naturaleza jurídica de la asamblea de accionistas, único órgano social autorizado para llevar a cabo tales modificaciones, del acuerdo de voluntades vertido por los socios en el acto constitutivo de la sociedad.

Si la sociedad anónima se constituye por acto único, el instrumento de constitución debe contener los requisitos exigidos por el art. 11 de la ley 19.550 y, además:

1. Respecto del capital social, la naturaleza, clases, modalidades de emisión y características de las acciones, y en su caso, régimen de aumento.

2. La suscripción del capital, el monto y la forma de integración y, si correspondiese, el plazo para el pago del saldo adeudado, que no podrá exceder de dos años.

3. La elección de los integrantes de los órganos de administración y de fiscalización, fijándose el término de duración en los cargos.

El contrato constitutivo de las sociedades anónimas deberá ser inscripto en el Registro Público, previa verificación de los requisitos legales y fiscales, e idéntico trámite debe cumplir el reglamento, para ser oponible a terceros.

§ 181. LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS UNIPERSONALES

La ley 26.994, que sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación, con vigencia desde el día 1 de agosto de 2015, así como las reformas a la ley 19.550 tendientes a compatibilizar el ordenamiento societario con el referido Código, incorporó a nuestra legislación las sociedades desde un solo socio.

Los requisitos de esta nueva figura legal son los siguientes:

a) Solo se permite que sean sociedades unipersonales las sociedades anónimas (art. 1º, ley 19.550).

b) La sociedad unipersonal solo puede ser constituida por instrumento público y por acto único (art. 165, ley 19.550).

c) No puede ser único socio otra sociedad unipersonal (art. 1º, ley 19.550).

d) La denominación debe ser "sociedad anónima unipersonal", su abreviatura o sigla "SAU" (art. 164, ley 19.550).

e) La integración del aporte debe ser en su totalidad al momento de su constitución (art. 187, ley 19.550).

f) La reducción a uno del número de socios de las sociedades anónimas no

unipersonales no conforma una causal de disolución de dichas compañías (art. 94 bis), sino que deben adecuar la denominación social a la exigencia del art. 164 para las sociedades unipersonales y cumplir con el régimen dispuesto por el art. 299, de la ley 19.550.

i) Están sujetas a la fiscalización estatal permanente (art. 299), de manera tal que, entre otras consecuencias, deben publicar los edictos de convocatoria a asambleas en el Boletín Oficial y en un diario de gran circulación (art. 237, ley 19.550), y deben contar con un directorio y sindicatura en forma obligatoria, que puede ser unipersonal (arts. 255 y 284, versión ley 27.290).

CAPÍTULO XX - SOCIEDADES ANÓNIMAS. EL CAPITAL SOCIAL

§ 185. IMPORTANCIA DEL CAPITAL SOCIAL. LA FUNCIÓN DE GARANTÍA QUE CUMPLE EL CAPITAL SOCIAL FRENTE A TERCEROS

La ley 19.550, advirtiendo la importancia fundamental del capital social en las sociedades anónimas, impone su imprescindible mención en el contrato constitutivo elevándolo a la categoría de "requisito esencial" en los términos del art. 17, inc. 2º, de dicho cuerpo normativo, de manera que su inexistencia, formal o sustancial, provocará el sometimiento de dicha sociedad al régimen previsto por la sección IV del capítulo I de la ley 19.550 (arts. 21 a 26), solución incorporada por la ley 26.994 que es un verdadero dislate, pues una sociedad sin capital social, donde sus integrantes responden en forma limitada por las obligaciones sociales, no puede ser pasible sino de la sanción de nulidad de la sociedad.

El capital social cumple tres funciones de importancia:

a) *De productividad*, función de contenido típicamente económico en virtud del cual el capital sirve como fondo patrimonial empleado para la obtención de un beneficio, a través del ejercicio de una determinada actividad empresarial.

b) *De determinación de la posición del socio en la entidad*, pues mediante el capital social se mide matemáticamente la participación y eventualmente la responsabilidad de los socios en las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.

c) *De garantía* frente a los acreedores sociales.

De todas estas funciones, la de garantía frente a los acreedores es la que asume el papel más destacado, pudiendo sostenerse que el capital sirve de instrumento de garantía que compensa a los acreedores de la exoneración de responsabilidad de que gozan los patrimonios personales de cada uno de los socios, en especial en las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. En otras palabras, la cifra capital brinda a estos un dato de fundamental importancia, pues les permite conocer los bienes, dinerarios o no, con que cuenta la sociedad para responder frente a terceros por las obligaciones sociales.

Es precisamente en cumplimiento de tal función, que la ley 19.550 ha dispuesto una serie de normas que tienden a preservar la intangibilidad del

capital social, en resguardo y protección no solo de quienes la integran, sino fundamentalmente en defensa de los acreedores sociales.

CAPÍTULO XXI - SOCIEDAD ANÓNIMA. ACCIONES, BONOS, DEBENTURES Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES

§ 195. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES. DERECHOS QUE CONFIEREN

El art. 163 de la ley 19.550 ha erigido a la división del capital en acciones como requisito esencial tipificante de las sociedades anónimas, según la terminología utilizada por el art. 17 de la ley 19.550.

La acción acredita la posición de su titular en relación con la sociedad emisora, fijando su participación en ella y estableciendo a partir de su suscripción una situación que presupone una compleja trama de facultades, derechos, cargas y obligaciones del socio respecto de la sociedad y viceversa. En otras palabras, la acción incorpora en sí la condición de socio.

Ahora bien, para tener tal virtualidad no es necesario que la acción deba estar representada en títulos circulatorios y que su titular deba exhibirlos al momento del ejercicio de sus derechos societarios, pues el estado de socio se adquiere desde el momento en que ellas se suscriben, independientemente de la entrega de los títulos al accionista.

Si bien las acciones deben tener siempre el mismo valor, expresado en moneda argentina, no admitiendo nuestra legislación la emisión de acciones sinvalor nominal, nada obsta a que aquellas confieran diferentes derechos. Surge de tal manera la posibilidad de creación, por parte de los fundadores o accionistas, de diversas clases o categorías de acciones, pero dentro de cada una de estas clases o categorías los derechos deben ser siempre idénticos (art. 207, ley 19.550).

La ley 19.550 no impone la necesidad de emitir títulos accionarios, a punto tal que el estatuto puede autorizar que todas las acciones o alguna de sus clases no se representen en títulos (art. 208, párr. 5º). Esta particular clase de acciones ha sido receptada por la ley 22.903, que la ha incorporado a nuestra legislación con el nombre de "acciones escriturales", cuya emisión, transferencia, gravámenes y constitución de derechos reales sobre ellas debe ser inscripta en cuentas llevadas a nombre de sus titulares por la sociedad emisora, por bancos comerciales o de inversión o caja de valores autorizados.

La calidad de accionista del titular de las acciones escriturales se presume por las constancias de las cuentas abiertas en el registro de acciones escriturales y la sociedad es siempre responsable ante los accionistas por los errores e irregularidades de las cuentas, sin perjuicio de la responsabilidad del banco o caja de valores ante la sociedad, en su caso.

Para acreditar el carácter de titular de acciones escriturales, el art. 208, *in fine*, de la ley 19.550 prevé que la sociedad, entidad bancaria o la caja de valores deben entregar al accionista el comprobante de la apertura de su cuenta y de todo movimiento que se inscriba en ella. Todo accionista tiene además derecho a que se le entregue, en todo tiempo, constancia del saldo de su cuenta, a su costa.

§ 196. CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

Las acciones pueden ser divididas desde numerosos puntos de vista:

1. Desde el punto de vista de su circulación, las acciones se dividen en acciones al portador, nominativas endosables y nominativas no endosables.
2. Desde el punto de vista de los derechos que confieren, las acciones pueden clasificarse en acciones privilegiadas, preferidas u ordinarias.

a) Son acciones *privilegiadas* o de voto plural, aquellas que confieren más de un voto por acción. Si bien nuestra legislación admite esta categoría de acciones (art. 216, ley 19.550), las somete a una serie de restricciones y, en tal sentido, ellas no pueden ser emitidas una vez que la sociedad emisora haya sido autorizada a hacer oferta pública de sus acciones. Del mismo modo, cuando se trata de la adopción de ciertos acuerdos assemblearios que implican la reforma sustancial del estatuto de la sociedad emisora, ellas pierden el voto múltiple,

confiriendo un solo voto por acción (art. 244, *in fine*, ley 19.550).

b) Son acciones *preferidas* aquellas que confieren a sus titulares determinados derechos patrimoniales que pueden asumir las siguientes modalidades:

c) Las acciones ordinarias, por definición *a contrario*, son aquellas que confieren un voto por acción y que carecen de preferencias patrimoniales.

§ 197. TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES

En principio, y como rasgo característico de las acciones, estas son libremente transmisibles y el estatuto solo puede limitar la transferencia de las acciones nominativas o escriturales, sin que ello importe la prohibición de su transferencia. La limitación debe constar en el título o en las inscripciones en cuenta, sus comprobantes y estado respectivo (art. 214, ley 19.550).

§ 202. NEGOCIACIONES SOBRE ACCIONES

En tanto las acciones de una sociedad anónima son "cosas" valiosas, ellas pueden ser objeto de diferentes negocios jurídicos.

§ 203. EMBARGO Y EJECUCIÓN DE ACCIONES

La ley 19.550 en sus arts. 56 y 219 acepta la posibilidad de que los acreedores particulares del accionista embarguen las acciones de que es titular su deudor, para su posterior ejecución forzada. En el ínterin en que se lleva a cabo la subasta, el propietario de las acciones es el único legitimado a ejercer todos los derechos societarios, debiendo el acreedor embargante facilitar el ejercicio de ellos. La ejecución forzada de las acciones se rige por lo dispuesto por el art. 562 del Cód. Civ. y Com.

§ 206. LOS BONOS. BONOS DE GOCE Y BONOS DE PARTICIPACIÓN

Los bonos son títulos que puede emitir la sociedad, de naturaleza diferente a las acciones, y que otorgan a sus titulares el derecho de participar exclusivamente en las utilidades sociales, que se autorizan a emitir en determinados supuestos.

§ 207. LOS DEBENTURES

Los debentures constituyen títulos de deuda que pueden emitir exclusivamente las sociedades por acciones, siempre y cuando tal emisión estuviere expresamente prevista en los estatutos.

§ 208. LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES

La ley 23.962 de Obligaciones Negociables, si bien ha tomado como fuente, entre otros antecedentes legislativos, las normas que los arts. 325 a 360 de la ley 19.550 dedican a los debentures, ha incorporado también una serie de disposiciones que alientan la emisión de este tipo de títulos de deuda y que ofrecen innumerables ventajas sobre los debentures:

a) En primer lugar, las obligaciones negociables pueden ser emitidas por sociedades por acciones, cooperativas, asociaciones civiles constituidas en el país y sucursales de sociedades por acciones extranjeras constituidas en los términos del art. 118 de la ley 19.550, con lo cual se ha ampliado acertadamente el mercado de los títulos de deuda privada, reservado históricamente para las sociedades por acciones.

b) Las obligaciones negociables pueden ser emitidas con cláusula de reajuste de capital, conforme a pautas objetivas de estabilización y pueden otorgar un interés fijo o variable.

c) Se establece para las obligaciones negociables un régimen de libertad de salida y regreso del país.

d) Se reglamenta en forma más minuciosa y detallada el régimen de obligaciones convertibles en acciones, cuya opción es otorgada exclusivamente al obligacionista para convertirse en titular de acciones de la sociedad emisora.

e) Se flexibiliza el régimen de emisión de las obligaciones negociables, cuando estas son emitidas por sociedades por acciones o cooperativas, en las cuales, y a diferencia de los debentures, no se requiere la autorización de los estatutos o su modificación en caso contrario. En tales entidades, la emisión de obligaciones negociables puede ser resuelta por una asamblea general ordinaria, salvo las

obligaciones convertibles en acciones, cuya emisión es competencia de las asambleas extraordinarias, con excepción de las sociedades autorizadas a hacer oferta pública de sus acciones.

f) No es obligatorio para la sociedad emisora recurrir a una institución bancaria o financiera, mediante la celebración de un contrato de fideicomiso, para la defensa de los derechos o intereses que colectivamente correspondan a los obligacionistas, y aun recurriéndose a dichas instituciones, estas no tienen las exorbitantes facultades que la ley 19.550, en materia de debentures, pone en manos del fiduciario, que llegan incluso, como se ha visto, a pedir la suspensión del órgano de administración de la emisora en supuestos excepcionales o a pedir incluso su liquidación.

g) Es también ponderable, en la ley 23.962, el equilibrio logrado para no restringir ni afectar las facultades de reorganización de la sociedad emisora, sin lesionar los intereses de los obligacionistas, a quienes se les otorga, frente a determinados supuestos, el ejercicio de ciertos derechos

h) Se prevé la emisión de obligaciones negociables no incorporadas a títulos, adaptando para estas el régimen de las acciones escriturales previstas por el art. 208 de la ley 19.550.

i) Finalmente, y sin detenernos en otros aciertos de la ley 23.962, se incorporan importantísimos beneficios fiscales, lo cual constituye un ingrediente fundamental de seducción para la emisión de obligaciones negociables, del cual carecía la regulación prevista por la ley 19.550 en materia de debentures.

CAPÍTULO XXII - LAS ASAMBLEAS DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

§ 209. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS

Puede definirse a la asamblea como la reunión de los accionistas convocada y celebrada de acuerdo con la ley y los estatutos, para considerar y resolver sobre los asuntos indicados en la convocatoria.

Son características de las asambleas de accionistas:

a) Es el órgano de gobierno de la sociedad, lo cual implica que no es asamblea cualquier reunión de accionistas, sino aquella que es convocada y celebrada conforme a la ley y los estatutos con todas las formalidades legales, y cuyas decisiones, obtenidas a través del régimen de mayorías, son obligatorias para todos los integrantes de la sociedad, atribuyéndose a esta las consecuencias y efectos que se deriven de tales acuerdos.

b) Es un órgano no permanente de la sociedad, en el sentido de que no funciona ininterrumpidamente durante toda la existencia de la sociedad, sino cuando es convocada por el órgano de administración de la compañía, quien deberá hacerlo una vez por año, dentro de los cuatro meses del cierre del ejercicio, para considerar los balances y estados contables, la política de ganancias, la gestión de los directores y síndicos y su remuneración. El incumplimiento de esta expresa directiva es suficiente causal de remoción de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de la sociedad.

c) Sus facultades son indelegables, por cuanto su competencia es exclusiva y no puede ser suplida por decisiones de otros órganos de la sociedad. Por las mismas razones, no puede la asamblea de accionistas invadir esferas reservadas a otros órganos sociales, habiéndose sostenido que los vicios de competencia generan nulidades absolutas, inconfirmables e imprescriptibles.

d) La validez de sus decisiones implica el respeto de la legalidad en todas y cada una de las etapas formativas de la voluntad social. La asamblea de accionistas es un acto formal *ad solemnitatem*, regulado por el legislador en forma muy minuciosa, para permitir la participación de todos los accionistas y evitar el abuso por parte del grupo de control.

e) Sus decisiones, en tanto respeten el estatuto y el ordenamiento legal, son obligatorias para todos los accionistas, que deben acatar la decisión de la mayoría, y deben ser cumplidas por el directorio.

§ 218. EL DERECHO DE RECESO

El derecho de receso, cuyo contenido hemos ya analizado, tiene por objetivo compatibilizar dos intereses igualmente legítimos: el de la sociedad para modificar sus estatutos y el derecho individual del accionista de no aceptar tales modificaciones cuando con estas se altera sustancialmente la sociedad de la cual forma parte, desvinculándose de ella, con reembolso del valor de su participación.

No cualquier modificación estatutaria otorga a los socios disconformes el

derecho de receso. El art. 245 de la ley 19.550 menciona a la transformación, prórroga, reconducción, excepto de las sociedades que hacen oferta pública o cotización de sus acciones, la transferencia del domicilio al extranjero, el cambio fundamental del objeto, la fusión por incorporación para los accionistas de la sociedad fusionada, la escisión, el aumento del capital social siempre y cuando su decisión competa a la asamblea extraordinaria e implique efectivos desembolsos para los socios, el retiro voluntario de la oferta pública o de cotización de las acciones y la continuidad de la actividad de la sociedad anónima sancionada con la cancelación firme de la oferta pública o cotización.

CAPÍTULO XXIII - EL DIRECTORIO

§ 219. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

La **administración** de la sociedad anónima está a cargo de un directorio compuesto por uno o más directores designados, por regla general, a través de la decisión de la asamblea de accionistas (art. 255, ley 19.550). También pueden ser designados por el consejo de vigilancia, según lo autoriza el art. 280 de la ley 19.550.

A diferencia de lo que acontece con los restantes tipos societarios, en las **sociedades anónimas, la administración está escindida de la representación, la cual corresponde al presidente del directorio** o al vicepresidente, en caso de ausencia o impedimento –art. 268 de la ley 19.550–, sin perjuicio de que, por vía estatutaria se autorice que la representación de la sociedad se encuentre a cargo de uno o más directores, pero ello de manera alguna implica el desplazamiento del presidente del directorio en el uso de la firma social, que siempre es, por expresa directiva del art. 268 de la ley 19.550, el representante legal de la sociedad y cuya actuación priva sobre otros representantes estatutarios o convencionales.

Debe recordarse que a partir de la sanción de la ley 19.550, nuestro ordenamiento societario ha adoptado la teoría organicista, conforme a la cual los directores no son mandatarios de la sociedad, sino sus funcionarios; ergo, no son terceros los que actúan en nombre de la compañía, sino la sociedad misma, quienes lo hacen con arreglo a las atribuciones conferidas en el acto constitutivo, tesis basada en el mero conceptualismo y por ello sumamente cuestionable, sobre la cual nos hemos referido en el capítulo XI de este libro.

No es necesario ser accionista para ocupar un cargo en el directorio.

El directorio puede ser unipersonal o pluripersonal, según lo prescriba el estatuto o en cada asamblea ordinaria prevista por el art. 234, inc. 2º, de la ley 19.550, en este último caso, dentro del número de integrantes previsto en el acto constitutivo. Las sociedades anónimas unipersonales, para las cuales la ley 26.994 previó un directorio de tres integrantes, fue modificada por la ley 27.290 del 17 de noviembre de 2016, permitiéndoles contar con un solo director, sin existir inconveniente legal para que el cargo de único director pueda recaer en manos del accionista único, lo cual con toda seguridad provocará no solo un permanente conflicto de interés, de muy difícil resolución, sino la intervención de la Inspección General de Justicia, atento a que las sociedades anónimas

unipersonales están incluidas dentro de aquellas compañías sometidas a la fiscalización permanente del Estado (art. 299, ley 19.550).

Si el directorio es plural, sus integrantes deben actuar colegiadamente, esto es, sesionar y decidir por mayoría cada uno de los aspectos de la gestión social. Por ello, el art. 274 de la ley 19.550 establece como principio general la responsabilidad solidaria e ilimitada de todos ellos por los daños y perjuicios sufridos por la sociedad, los accionistas y los terceros como consecuencia de su actuación.

El estatuto debe precisar el término por el cual los directores son elegidos, el que no puede exceder los tres ejercicios. Ello no significa que los directores deben dejar el cargo el último día del ejercicio por el cual fueron designados, sino que deben permanecer en él hasta su efectivo reemplazo, que por lo general se produce en la asamblea ordinaria que considera los balances y estados contables correspondientes al período en el cual se desempeñaron, para cuya convocatoria el directorio cuenta con cuatro meses luego de cerrado el ejercicio (art. 234, *in fine*, ley 19.550).

Al asumir el cargo, los directores deben prestar una garantía para responder por los eventuales daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de su mala gestión. Al respecto, el art. 256, párr. 2º, dispone que el estatuto debe establecer la naturaleza y clase de dicha garantía, pero que nunca puede consistir en las acciones de la compañía que administran (art. 222, ley 19.550). Sin embargo, esta disposición que encuentra razonable fundamento a los fines de no tornar ilusorio el resultado de futuras acciones de responsabilidad contra ellos ha sido desvirtuada en la práctica, otorgándose garantías irrisorias que enervan las loables intenciones del legislador. Es más, los estatutos modelo elaborados por la autoridad de contralor han contribuido a fomentar esa mala costumbre al establecer garantías meramente simbólicas y que no guardan la menor relación con el giro social. Precisamente, y para evitar garantías absurdas, cuyo monto jamás pueden depender de los órganos sociales, la Inspección General de Justicia ha previsto en los arts. 75 a 77, resolución general 7/2015, determinadas previsiones, tendientes a evitar que la finalidad que desempeña la garantía que deben prestar los directores sea totalmente desvirtuada mediante la fijación estatutaria o asamblearia de cifras ridículas, como venía sucediendo.

§ 221. REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES

La función de director es remunerada, y si los estatutos nada dicen sobre ello, es la asamblea general ordinaria de accionistas quien debe fijar la retribución (art. 234, inc. 2º, ley 19.550).

El art. 261 de la ley 19.550, que legisla sobre el tema, ha pretendido balancear la importante función que cumple el director y su correspondiente derecho a la retribución, con el derecho de los accionistas a la percepción del dividendo, estableciendo un sistema que evita la existencia de administradores ricos y accionistas pobres. En tal sentido, dispone el art. 261, párr. 2º, que el monto máximo que por todo concepto pueden percibir los miembros del directorio y del consejo de vigilancia, en su caso, incluidos sueldos y otras remuneraciones por

el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente, no podrá exceder del 25% de las ganancias.

§ 229. RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES

Los directores de las sociedades anónimas responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros por el mal desempeño de su cargo, según el criterio de lealtad y diligencia previsto por el art. 59 de la ley 19.550, así como por la violación de la ley, estatuto o el reglamento, y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave (art. 274, párr. 1º, ley 19.550).

CAPÍTULO XXIV - EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS. EL CONSEJO DE VIGILANCIA Y LA SINDICATURA. LA FISCALIZACIÓN EXTERNA

§ 233. EL CONSEJO DE VIGILANCIA

Se trata de un órgano de fiscalización colegiado, no profesional, integrado por tres a quince accionistas, cuya existencia deberá estar expresamente prevista por el estatuto, el cual deberá reglamentar su organización y funcionamiento (arts. 280 y 281, ley 19.550).

§ 234. LA SINDICATURA

La fiscalización privada de la sociedad anónima está a cargo de uno o más síndicos designados por la asamblea de accionistas, la cual elegirá igual número de síndicos suplentes (art. 284, ley 19.550).

Las sociedades anónimas no comprendidas en el art. 299 pueden prescindir de este órgano, siendo optativa su constitución, pero el estatuto debe prever especialmente esta prescindencia. En tal caso, los socios poseen el derecho de control previsto por el art. 55 de la ley 19.550, pero cuando por aumento del capital social se exceda el monto previsto por el inc. 2º del art. 299, para las cuales la sindicatura es obligatoria, la asamblea que así lo resuelva debe designar síndico, sin que sea necesaria la reforma del estatuto.

§ 236. ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA SINDICATURA

El síndico debe ejercer sus funciones en forma personal, siendo su cargo indelegable (art. 293, ley 19.550). En el caso de sociedades integradas por abogados o contadores rigen las normas que para las sociedades colectivas disponen los arts. 127 a 130 de la ley 19.550.

El art. 294 enumera los derechos y deberes de la sindicatura. Ellos son:

1. Fiscalizar la administración de la sociedad, a cuyo efecto examinará los libros y documentación, siempre que lo juzgue conveniente y por lo menos una vez cada tres meses.

2. Verificar en igual forma y periodicidad las disponibilidades y títulos valores, así como las obligaciones y su cumplimiento; igualmente puede solicitar al directorio la confección de balances de comprobación.

3. Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del directorio, del comité ejecutivo y de la asamblea, a todas las cuales debe ser especialmente citado. Esta obligación tiene su correlato en el art. 297 de la ley 19.550, que tiende a que el síndico conozca las resoluciones administrativas y los negocios sociales, de manera que pueda asumir su responsabilidad solidaria con los directores por los hechos u omisiones de estos.

4. Controlar la constitución y subsistencia de la garantía de los directores y recabar las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad.

5. Presentar a la asamblea ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados. Esta es quizás la función más importante de la sindicatura y en la cual su independencia de criterio debe manifestarse con mayor nitidez, pues constituye un instrumento fundamental para que los accionistas, sin cargo en el órgano de administración, puedan confiar en los estados contables que le son presentados para su consideración y aprobación en la asamblea ordinaria.

6. Suministrar a accionistas que representen no menos del 2% del capital social, en cualquier momento que estos lo requieran, informaciones sobre las materias que son de su competencia.

7. Convocar a asamblea extraordinaria cuando lo juzgue necesario y a asamblea ordinaria o asambleas especiales cuando omitiere hacerlo el directorio.

8. Hacer incluir en el orden del día de la asamblea los puntos que considere procedentes.

9. Vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias. Esta es, en términos generales, la función que caracteriza y justifica la existencia de la sindicatura en la sociedad, pues a través de tal vigilancia puede ejercer el control de legalidad en el funcionamiento de la sociedad que le ha sido expresamente confiado.

10. Fiscalizar la liquidación de la sociedad.

11. Investigar las denuncias que le formulen por escrito accionistas que representen no menos del 2% del capital, mencionarlas en informe verbal a la asamblea y expresar acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que correspondan. Debe convocar de inmediato a asamblea para que resuelva al respecto, cuando la situación investigada no reciba del directorio el tratamiento que conceptúe adecuado y juzgue necesario actuar con urgencia.

§ 241. FISCALIZACIÓN ESTATAL O EXTERNA

Además de la fiscalización interna de las sociedades anónimas, la ley 19.550 ha impuesto un régimen de control externo, a cargo de la Inspección General de Justicia de la Capital Federal, cuyos alcances difieren según la clase de sociedad de que se trata:

a) Si se trata de las sociedades comprendidas en el art. 299, esto es, aquellas que hagan oferta pública de sus acciones (inc. 1º); tengan un capital social superior a la suma de 40.000.000 pesos (inc. 2º); sean de economía mixta o de participación estatal mayoritaria (inc. 3º); realicen operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requieran dinero o valores al público con promesa de prestaciones o beneficios futuros (inc. 4º); exploten concesiones o servicios públicos (inc. 5º); se trate de sociedad controlada o controlante por algunas de las sociedades referidas en los incisos anteriores (inc. 6º); o se trata de sociedades anónima unipersonales (inc. 7º), estas se encuentran sometidas, además del control de legalidad en el acto de su constitución, a la fiscalización permanente por parte de la autoridad de control de su domicilio, durante su funcionamiento, disolución y liquidación. Se aclara que salvo las sociedades anónimas unipersonales, las demás sociedades comprendidas en el art. 299 deben contar con un directorio integrado de tres directores como mínimo, pues por disposición expresa de la ley 27.290, que reformó el art. 255, las SAU pueden contar con solo un integrante, y con la misma filosofía, dicha ley modificó el art. 284 de la ley 19.550, eximiendo de la sindicatura plural impar a las sociedades incluidas en el art. 299 de la ley 19.550, a aquellas compañías mencionadas en los incs. 2º y 7º del art. 284 –sociedades de un capital social superior a la suma de pesos 40.000.000 y sociedades anónimas unipersonales–, las cuales pueden integrar el órgano de control interno con solo un síndico.

b) Si la sociedad anónima no se encuentra incluida entre aquellas compañías mencionadas por el art. 299, su fiscalización estatal se limitará al contrato constitutivo, sus reformas y variaciones del capital y valuación de sus aportes en especie (art. 300, ley 19.550), pero la autoridad de control podrá ejercer funciones de vigilancia en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando lo soliciten accionistas que representen el 10% del capital suscrito o lo requiera cualquier síndico, pero en este caso se limitará a los hechos que frenen la presentación.

2. Cuando lo considere necesario, según resolución fundada, en resguardo del interés público.

CAPÍTULO XXV - SOCIEDADES ANÓNIMAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

§ 242. LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

Las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria son aquellas en las cuales el Estado nacional, los Estados provinciales, los municipales, los organismos estatales autorizados al efecto o las sociedades anónimas sujetas a este régimen sean propietarios en forma individual o conjunta de acciones que representen por lo menos el 51% del capital social y sean suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias.

La ley 19.550 dedica a este subtipo de sociedades los arts. 308 a 312, dentro de los cuales quedan también comprendidas las sociedades anónimas en las que se reúnan con posterioridad al contrato de constitución los requisitos mencionados en el párrafo anterior, siempre que una asamblea especialmente convocada al efecto así lo determine y que no mediere en ella oposición expresa de algún accionista (art. 309, ley 19.550).

La concurrencia de los dos requisitos exigidos por el art. 308 de la ley 19.550 (51% del capital social y los votos suficientes para prevalecer en las

asambleas ordinarias y extraordinarias) puede llevar a interpretaciones equivocadas, pues aquel porcentaje resulta insuficiente para celebrar asambleas extraordinarias en primera convocatoria. Por ello, coincidiendo con la jurisprudencia, debe interpretarse que es requisito imprescindible, de conformidad con las normas legales señaladas, que las acciones de propiedad estatal deben ser suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias, lo cual significa que el Estado debe tener *quorum* propio y el número suficiente de votos para decidir cualquier cuestión encuadrable en el orden del día, de lo cual es conclusión necesaria que el Estado debe ser titular de por lo menos el 60% del capital social.

La especial naturaleza de estas sociedades ha originado una polémica sobre la competencia de los tribunales que deben entender en los conflictos en que ellas sean parte, pues de entenderse que son personas jurídicas de derecho público, la competencia del fuero federal resulta indiscutible. Sin embargo, la jurisprudencia se ha pronunciado por la intervención del fuero comercial en aquellos supuestos, con el lógico argumento de que las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria son sociedades conformadas bajo una regulación especial del derecho privado, pues más allá de la aplicación del derecho público que corresponda en algunos y determinados aspectos, ellas se rigen por las normas comunes del derecho mercantil.